

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5172/2566

พนักงานอัยการจังหวัด  
นาย อ.

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 228

ป.วิ.พ. มาตรา 120

การที่ผู้เสียหายทั้งหกมาเบิกความภายหลังแม้จะขัดแย้งกับคำให้การชั้นสอบสวนและคำเบิกความชั้นสืบพยานก่อนฟ้อง แต่ก็เป็น การเบิกความเพื่อพิสูจน์ความจริงให้กระจ่างชัดว่ามีเหตุผลอย่างไรทำไมถึงให้การชั้นสอบสวนและเบิกความต่อศาลชั้นต้นฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงไว้เช่นนั้น หากใช่เป็นการเบิกความเพื่อช่วยเหลือจำเลยดังที่โจทก์ฎีกาไม่ แม็คดีอยู่ระหว่างสืบพยานจำเลย ซึ่งโดยผลการหรือคู่ความฝ่ายใดร้องขอ ศาลมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติมจะสืบเองหรือส่งประเด็นก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 228 และตาม ป.วิ.พ. มาตรา 120 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 15 ถ้าคู่ความฝ่ายใดอ้างว่าคำเบิกความของพยานคนใดที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างไม่ควรรับฟัง โดยเหตุผลซึ่งศาลเห็นว่ามีมูล ศาลอาจยอมให้คู่ความฝ่ายนั้นนำพยานหลักฐานมาสืบสนับสนุนข้ออ้างของตนได้แล้วแต่จะเห็นควร คดีนี้จำเลยนำสืบปฏิเสธฟ้องโจทก์ว่า ผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิง อ. ให้การชั้นสอบสวนและเบิกความชั้นสืบพยานก่อนฟ้องไปโดยถูกควบคุมตัว ข่มขู่ ไม่ให้กลับบ้านและพบบิดามารดา คำให้การชั้นสอบสวนและคำเบิกความดังกล่าวไม่ควรรับฟัง เมื่อทนายจำเลยแถลงขอสืบพยานผู้เสียหายทั้งหก หากศาลเห็นว่า เป็นพยานหลักฐานสำคัญที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลก็ชอบที่จะอนุญาตให้จำเลยนำผู้เสียหายทั้ง

หกเข้าเบิกความตามมาตราดังกล่าวข้างต้น และมีคำสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณา  
ได้ จำต้องให้จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลก่อนดังที่โจทก์กล่าวอ้างในฎีกาแต่  
อย่างใดไม่

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 11, 12, 13, 18, 62, 81 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91,  
278, 279 นับโทษจำคุกของจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญา  
หมายเลขดำที่ ย 407/2563 และหมายเลขดำที่ ย 520/2564 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้  
นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.  
2522 มาตรา 11, 18 วรรคสอง, 62 วรรคหนึ่ง, 81 การกระทำของจำเลยเป็นความ  
ผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ  
อนุญาต จำคุก 4 เดือน ฐานเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต  
จำคุก 4 เดือน รวมจำคุก 8 เดือน นับโทษจำคุกจำเลยต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญา  
หมายเลขดำที่ ย 407/2563 หมายเลขแดงที่ ย 555/2564 และคดีอาญาหมายเลข  
ดำที่ ย 520/2564 หมายเลขแดงที่ ย 268/2565 ของศาลชั้นต้น ข้อหาอื่นนอกจากนี้  
ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

## ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษายืน

### โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุนาย พ. ผู้เสียหายที่ 1 อายุ 16 ปีเศษ เด็กชาย ข. ผู้เสียหายที่ 2 อายุ 13 ปีเศษ เด็กชาย ว. ผู้เสียหายที่ 3 อายุ 13 ปีเศษ เด็กชาย ย. ผู้เสียหายที่ 4 อายุ 13 ปีเศษ นาย ข. ผู้เสียหายที่ 5 อายุ 15 ปีเศษ เด็กชาย ต. ผู้เสียหายที่ 6 อายุ 13 ปีเศษ แพทย์ตรวจร่างกายผู้เสียหายทั้งหกไม่พบบาดแผลที่ทวารหนักและอวัยวะเพศ ไม่พบตัวอสุจิและส่วนประกอบของน้ำอสุจิที่ปากทวารหนัก ทั้งไม่พบหลักฐานการกระทำชำเราผู้เสียหายทั้งหก ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ สำหรับความผิดฐานเป็น คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์และฎีกา จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีโดยใช้อวัยวะอื่นซึ่งไม่ใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำทวารหนักของเด็ก และกระทำอนาจารแก่เด็กอายุกว่าสิบห้าปีโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตามฟ้องข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.6 หรือไม่ เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงได้ความจากพยานโจทก์ว่า ผู้เสียหายทั้งหก และเด็กหญิง อ. ให้การต่อพนักงานสอบสวน และเบิกความเป็นพยานโจทก์ชั้นสืบพยานก่อนฟ้องในทำนองว่า ผู้เสียหายทั้งหกถูกจำเลย กอด จูบ ดูปาก จับและอมอวัยวะเพศ และใช้นิ้วมือล่วงล้ำทวารหนักของผู้เสียหายที่ 6 อันเป็นการกระทำอนาจาร เด็กหญิง อ. เคยเห็นจำเลยกอดจูบเด็กคนอื่น และนางสาว พ. กับนางสาว น. เบิกความว่า พยานทั้งสองร่วมกันสอบข้อเท็จจริงผู้เสียหายทั้งหก และเด็กหญิง

อ. โดยผู้เสียหายที่ 6 ให้การว่า ถูกจำเลยล่วงละเมิดทางเพศด้วยการกอด จับ อวัยวะเพศและใช้นิ้วสอดใส่ทวารหนัก จึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลย แต่ผู้เสียหายทั้งหกกลับเบิกความเป็นพยานจำเลยว่า จำเลยไม่เคยกระทำอนาจารหรือล่วงละเมิดทางเพศกับผู้เสียหายทั้งหก ผู้เสียหายทั้งหกถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจภูธร 14 วัน เหตุที่ผู้เสียหายทั้งหกให้การต่อพนักงานสอบสวนและเบิกความขึ้นสืบพยานก่อนฟ้องว่าถูกจำเลยกระทำอนาจาร เนื่องจากผู้เสียหายทั้งหกถูกข่มขู่ว่าหากไม่ให้การและเบิกความเช่นนั้นจะติดคุก ถูกทำร้าย กักขัง ไม่ให้กลับบ้านพบกับบิดามารดาผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิง อ. เกิดความกลัวจึงให้การและเบิกความไปเช่นนั้น ซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของนางสาว น. และพันตำรวจโท ธ. พยานโจทก์ว่า มีการนำผู้เสียหายทั้งหกไปที่สถานีตำรวจภูธร และคำให้การชั้นสอบสวนของนาง อ. มารดาผู้เสียหายที่ 3 นาง ม. มารดาผู้เสียหายที่ 2 นาง จ. มารดาผู้เสียหายที่ 6 นางสาว ข. พี่สาวผู้เสียหายที่ 5 ทำนองเดียวกันว่า ทราบเรื่องผู้เสียหายทั้งหกถูกจับหรือถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูธร และคำเบิกความของนาง จ.ว่า ผู้เสียหายที่ 6 ถูกควบคุมตัว 14 วัน ผู้เสียหายที่ 6 เล่าให้ฟังว่า เจ้าหน้าที่บอกผู้เสียหายที่ 6 พูดยตามที่ได้เจ้าหน้าที่ต้องการ มิฉะนั้นจะถูกจับกุมดำเนินคดี ผู้เสียหายที่ 6 หวาดกลัวนั้น เชื่อได้ว่าการสอบคำให้การชั้นสอบสวนและการเบิกความขึ้นสืบพยานก่อนฟ้องของผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิง อ. เกิดขึ้นระหว่างที่ถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจภูธร มีการจู่โจม ขู่เข็ญ หลอกลวง และทำร้ายร่างกาย การที่ผู้เสียหายทั้งหกมาเบิกความภายหลังแม้จะขัดแย้งกับคำให้การชั้นสอบสวนและคำเบิกความขึ้นสืบพยานก่อนฟ้อง แต่ก็เป็น การเบิกความเพื่อพิสูจน์ความจริงให้กระจ่างชัดว่ามีเหตุผลอย่างไรทำไมถึงให้การในชั้นสอบสวนและเบิกความต่อศาลชั้นต้นที่ ผิดแผกต่อความเป็นจริงไว้เช่นนั้น หากใช่เป็นการเบิกความเพื่อช่วยเหลือจำเลยดังที่ โจทก์ฎีกาแต่อย่างใดไม่ แม้อาศัยอยู่ระหว่างสืบพยานจำเลยซึ่งโดยผลการหรือคู่ความ ฝ่ายใดร้องขอ ศาลมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติมจะสืบเองหรือส่งประเด็นก็ได้ ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 228 และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 120 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ถ้าคู่ความฝ่ายใดอ้างว่าคำเบิกความของพยานคนใดที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างไม่ควรเชื่อฟัง โดยเหตุผลซึ่งศาลเห็นว่ามีมูล ศาลอาจยอมให้คู่ความฝ่ายนั้นนำพยานหลักฐานมาสืบสนับสนุนข้ออ้างของตนได้แล้วแต่จะเห็นควร คดีนี้จำเลยนำสืบปฏิเสธฟ้องโจทก์ว่า ผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิง อ. ให้การชั้นสอบสวนและเบิกความชั้นสืบพยานก่อนฟ้องไปโดยถูกควบคุมตัว ช่มชู้ ไม่ให้กลับบ้านและพบบิดามารดา คำให้การชั้นสอบสวนและคำเบิกความดังกล่าวไม่ควรเชื่อฟัง เมื่อทนายจำเลยแถลงขอสืบพยานผู้เสียหายทั้งหก หากศาลเห็นว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลก็ชอบที่จะอนุญาตให้จำเลยนำผู้เสียหายทั้งหกเข้าเบิกความตามมาตราดังกล่าวข้างต้น และมีคำสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาได้ หากจำต้องให้จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลก่อนดังที่โจทก์กล่าวอ้างในฎีกาแต่อย่างใดไม่ เมื่อตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 บัญญัติว่า "พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการจงใจ มีคำมั่นสัญญา ชูเชิญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น..." แต่พฤติการณ์ในคดีนี้พยานบุคคลและพยานเอกสารซึ่งเป็นผู้เสียหายทั้งหก และเด็กหญิง อ. ยังเป็นผู้เยาว์มีอายุไม่มากและอ่อนประสบการณ์ถูกควบคุมตัวโดยมีคนดูแลและปิดประตูล็อกไว้ การสอบคำให้การชั้นสอบสวนและการเบิกความต่อศาลชั้นต้นสืบพยานก่อนฟ้องอาจเป็นไปตามที่ผู้ควบคุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการได้ แม้จะมีการสอบคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิง อ. ต่อหน้านักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ แต่ตามคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายที่ 1 และที่ 3 บุคคลที่เด็กร้องขอหรือผู้ที่

ไว้วางใจได้ลงลายชื่อในฐานะล่ามแปลด้วย โดยผู้เสียหายที่ 6 เบิกความโต้แย้งว่า มีล่ามข่มขู่จะให้เจ้าพนักงานตำรวจพาไปติดคุกหากไม่เบิกความว่า จำเลยกระทำอนาจาร ทำให้มีข้อระวางสงสัยว่าคำให้การชั้นสอบสวนและคำเบิกความชั้นสืบพยานก่อนฟ้องของผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิง อ. ได้ให้การและเบิกความไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ เนื่องจากเมื่อผู้เสียหายทั้งหก และเด็กหญิง อ. ให้การและเบิกความต่อศาลชั้นต้นแล้วยังถูกนำไปควบคุมตัวต่ออีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักในการสอบสวนคดีอาญาโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่มีบทบัญญัติมาตราใดให้มีการควบคุมตัวผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิง อ. ซึ่งเป็นพยานไว้ก่อนแล้วเอาตัวมาเบิกความต่อศาล แต่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง...อันเป็นการยากแก่การนำพยานนั้นมาสืบในภายหน้าจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสืบพยานนั้นไว้ทันทีก็ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 237 ทวิ การควบคุมตัวดังกล่าวย่อมเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายของผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิง อ. ซึ่งเป็นพยาน ประกอบกับการจับกุมและการคุมขังบุคคลดังกล่าวจะทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 28 การกระทำเช่นนี้จึงเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบ ซึ่งต้องห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 ทั้งในคดีอาญาโจทก์มีภาระการพิสูจน์ และศาลต้องใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชี้ขาดน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวง โดยจะไม่พิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคหนึ่ง ซึ่งคดีนี้ความผิดตามฟ้องโจทก์มีอัตราโทษจำคุกสูงถึงยี่สิบปี พยานโจทก์จะต้องชัดแจ้งหนักแน่น มั่นคงโดยไม่มีข้อตำหนิใด ๆ ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ได้ลักษณะแห่งคดีอยู่ในวิสัยที่โจทก์สามารถหาพยานหลักฐานด้วยวิธีการอันสุจริตและ

ชอบด้วยกฎหมายมาพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้ การรับฟังพยานหลักฐานโจทก์ที่ได้มาจากการแสวงหามาโดยมิชอบเท่ากับอนุญาตให้โจทก์นำพยานหลักฐานมาเพิ่มเติมในส่วนที่ตนนำสืบบกพร่องไว้ เพื่อจะลงโทษจำเลยแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของจำเลยและกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน อันเป็นการขัดต่อหลักการพื้นฐานของการดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไป เมื่อการวินิจฉัยชี้ว่านักพยานหลักฐานโจทก์ ศาลต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลย เว้นแต่จะมีเหตุผลอันหนักแน่นมีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี หรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227/1 วรรคหนึ่ง แต่พยานโจทก์ซึ่งเป็นคำเบิกความชั้นสืบพยานก่อนฟ้องและคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิง อ. ต้องห้ามมิให้รับฟังดังที่วินิจฉัยข้างต้นแล้ว พยานโจทก์ส่วนที่เหลือมีเพียงนางสาว พ. นางสาว น. และพันตำรวจโท ธ. ซึ่งเป็นพยานบอกเล่าไม่รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะที่กระทำความผิด และผลการตรวจชั้นสูตรบาดแผลของแพทย์ ไม่พบบาดแผลที่ทวารหนัก อวัยวะเพศ ไม่พบตัวอสุจิ ส่วนประกอบของน้ำอสุจิที่ปากทวารหนัก ภายในทวารหนักและไม่พบหลักฐานการกระทำชำเราของผู้เสียหายทั้งหก ส่วนสาเหตุที่นางสาว พ. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากบุคคลไม่ทราบชื่อมิใช่ผู้เสียหายทั้งหกหรือบิดามารดาของผู้เสียหายทั้งหก โดยผู้เสียหายทั้งหกไม่เคยเล่าเรื่องราวที่ถูกจำเลยกระทำอนาจารให้บิดามารดาหรือบุคคลอื่นล่วงรู้จึงเป็นเรื่องที่ผิดปกติวิสัยอย่างยิ่งหากมีการถูกกระทำอนาจารจริง ทั้งยังได้รับความจากผู้เสียหายที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 เบิกความตอบทนายผู้ต้องหาถามค้านชั้นสืบพยานก่อนฟ้องทำนองเดียวกันว่า ไม่อยากให้จำเลยถูกดำเนินคดี และอยากไปอยู่กับจำเลยอีก น่าเชื่อว่าจำเลยอาจถูกกลั่นแกล้งแจ้งความให้ดำเนินคดีตามข้อต่อสู้ของจำเลยก็เป็นได้ ประกอบกับจำเลยก็ให้การปฏิเสธมาตลอด

ดังนั้น พยานหลักฐานโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำความผิดตาม  
ฟ้องข้อ 1.1 ถึง 1.6 หรือไม่ จึงให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย ตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6  
พิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(นายนาวุธ จันทรจำเริญ-อรพงษ์ ศิริกานต์นนท์-ยุพา วงศ์ทองทิว)

ศาลจังหวัดแม่สอด - นายรณชัย โตงาม

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 - นายนพรัตน์ อักษร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ